

1000558-78.2019.8.26.0651

Classe: Ação Civil de Improbidade Administrativa

Assunto: Dano ao Erário

Magistrado: FERNANDO BALDI MARCHETTI

Comarca: Valparaíso

Foro: Foro de Valparaíso

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos" (Pazzagliani Filho, Marino; Elias Rosa, Márcio Fernando e Fazzio Júnior, Waldo. Improbidade Administrativa, Editora Atlas, 1996, p. 35).

O caráter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valparaíso

Foro de Valparaíso

1ª Vara

Rua Padre Mauro Eduardo s/nº, Valparaíso - SP - cep 16880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1000558-78.2019.8.26.0651 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000558-78.2019.8.26.0651

Classe - Assunto

Ação Civil de Improbidade Administrativa - Dano ao Erário

Requerente e Litisconsorte Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e outro

Requerido:

Roni Cláudio Bernardi Ferrareze e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO BALDI MARCHETTI

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente Ação de Responsabilidade Civil por ato de Improbidade Administrativa e de Ressarcimento ao Erário em face de RONI CLÁUDIO BERNARDI FERRAREZE, GISELE SALESSE, NATASCHA LEITE DE ALMEIDA, ROBSON DA SILVA COUTINHO, SERGIO FERREIRA DIAS, DIEGO NOVAIS SEVERIANO DOS SANTOS, JEAN PIERRE PEDROSO BARBOSA, MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO e FERCAL COMÉRCIO DE FERROS E CALHAS LTDA - ME alegando, em síntese, que em 20 de março de 2018 o Sr. Sebastião, representante legal da requerida Fercal, relatou suposta fraude e desvio de verba pública envolvendo sua empresa. Aduz que diante do relato, foi instaurado inquérito civil para apuração dos fatos. Sustenta que em razão das investigações, ficou constatado que o requerido Diego procurou o Sr. Sebastião e contratou, por dispensa de licitação, o serviço de confecção e instalação de 02 grades para

carroceria de caminhão de reciclagem, equivalente a R\$ 3.200,00. Informa que foi expedida a nota de empenho nº 7247/000 na data de 31/07/2017 e esta foi devidamente liquidada. Alega que prestado o serviço, o representante legal da requerida Fercal emitiu a nota eletrônica nº 21, e que de posse deste documento, o Sr. Sebastião solicitou que seu filho Jean fosse à Prefeitura para receber o valor devido. Aduz que o serviço foi pago mediante a expedição do cheque de nº 851083, no valor de R\$ 3.088,00. Sustenta que após a efetiva prestação do serviço de confecção e instalação de 02 grades para carroceria de caminhão de reciclagem e do pagamento deste, não prestou nenhum outro tipo de serviço ao Município. Alega que após o encerramento desta tratativa, os requeridos Roni, Gisele, Natacha, Robson, Sérgio, Diego e Jean se reuniram e armaram um grande esquema de desvio de verba pública, vez que simularam a prestação de serviços pela empresa Fercal, emitiram notas fiscais e de empenho em nome desta, liquidaram as notas e efetuaram pagamentos por serviços que não existiram. Aduz que esta conduta gerou a emissão indevida das notas fiscais eletrônicas de nº 22 e 35, todas em nome da requerida Fercal, e que houve um desvio de verba pública de aproximadamente R\$ 100.000,00. Sustenta que Jean é filho do representante do Sr. Sebastião e que, aproveitando-se desta situação, vez que de algum modo tinha acesso aos dados, ao perfil e à senha da empresa Fercal, acessou o sistema de tributação disponibilizado pela Prefeitura Municipal e, indevidamente, lançou diversas notas fiscais eletrônicas em nome da requerida Fercal sem o conhecimento e autorização de seu pai. Informa que concomitantemente a isso, as requeridas Gisele e Natasha emitiram notas de empenho e empenho parciais, respectivamente, ideologicamente falsas, na medida em que alimentaram o sistema de dados com informações falsas. Alega que as requeridas Gisele e Natasha, quando da liquidação das notas, procederam de forma irregular, vez que aquelas estavam desacompanhadas de qualquer solicitação de serviço, processo licitatório, autorização do Departamento de Compras, medição do Departamento de Obras, ou qualquer outro documento que comprovasse a efetiva realização do serviço. Aduz que o requerido Roni, valendo-se do poder e competência a ele investida, aderiu à conduta dos demais e contribuiu para que as fraudes fossem concretizadas, tendo encaminhado as notas para pagamento, tarefa afeta aos requeridos Sérgio e Robson. Informa que Sérgio e Robson agiram no interesse particular de cada um dos requeridos, pois, agindo como os demais requeridos, efetuaram o pagamento de serviços inexistentes sem se preocuparem em verificar se havia algum documento que atestasse a efetiva prestação do serviço. Sustenta ainda que os requeridos Sérgio e Robson inseriram, em documento público, declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, pois lançaram datas divergentes no relatório analítico de fornecedores. Mencionou que os requeridos Roni, Gisele, Sérgio, Robson, Natasha e Diego também atuaram sem a participação de Jean, pois a requerida Gisele, valendo-se dos amplos poderes e acesso irrestrito que tinha sobre o programa de emissão de nota fiscal eletrônica, aproveitou-se das falhas operacionais apresentadas pelo programa no segundo semestre do ano de 2017 e, valendo-se da senha e login da requerida Fercal, praticaram novas fraudes. Alega que no momento em que a fraude foi descoberta, a requerida Gisele, novamente se valendo da sua condição de gestora do contrato de concessão de uso de software utilizado para emissão de nota fiscal eletrônica, cancelou irregularmente as notas fiscais expedidas em nome da empresa Fercal. Afirma que os requeridos violaram diversos princípios aplicáveis à Administração pública, bem como enriqueceram ilicitamente e lesaram o erário.

Pugnou pela procedência da ação a fim de que seja reconhecida a prática, pelos requeridos Roni, Gisele, Natasha, Robson, Sergio, Diego e Jean, dos atos de improbidade narrados na exordial, aplicando-lhes as sanções previstas no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.429/92 ou, subsidiariamente, a pena dos incisos II e III, do referido Códex, devendo estes também serem condenados ao ressarcimento dos danos morais suportados pela coletividade; seja reconhecida a ilegalidade das relações jurídicas relatadas e a condenação do Município ao cumprimento de obrigação de fazer.

Juntou documentos (fls. 91/1345).

O pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos Roni, Gisele, Natasha, Robson, Sergio, Diego e Jean foi deferido (fls. 1348/1354).

Notificados (Gisele - fls. 1424, Natascha - fls. 1419, Robson - fls. 1417, Sérgio - fls. 1415, Diego - fls. 1421), os requeridos ofertaram manifestação por escrito (Gisele - fls. 1629/640, Natascha - fls. 1570/1576, Robson - fls. 1520/1535, Sérgio - fls. 1570/1576, Diego - fls. 1620/1626).

O requerido Roni compareceu de forma espontânea aos autos e ofertou manifestação por escrito (fls. 1447/1478).

Notificado (fls. 1426), o requerido Jean deixou de apresentar manifestação por escrito (fls. 1666).

A Fazenda Municipal foi intimada (fls. 1413), bem como a empresa Fercal (fls. 1428), mas não se manifestaram (fls. 1666).

A inicial foi recebida, determinando-se a citação dos requeridos (fls. 1682/1683).

O Município também foi citado (fls. 1704), assim como a empresa Fercal (fls. 1719).

Os requeridos foram citados (Gisele - fls. 1712, Natascha - fls. 1718, Robson - fls. 1706, Sérgio - fls. 1708, Diego - fls. 1716, Jean - fls. 1714).

Natascha apresentou contestação (fls. 1721/1744) alegando, em síntese, que não concorreu de qualquer forma para a prática do ato de improbidade indicado na exordial, agindo sempre de boa-fé e seguindo ordens de seus superiores. Aduz que não possuía condições de perceber a ocorrência de qualquer ilícito no procedimento de liquidação e que não atuou de forma a lesar o erário. Afirma que foi inocentada no âmbito administrativo e que não há provas de qualquer irregularidade praticada pela requerida. Sustenta que a inicial sequer descreveu a conduta dolosa da acusada e que não agiu com dolo, requerendo a improcedência da ação.

Gisele contestou o feito (fls. 1831/1842) sustentando, em resumo, que não praticou qualquer ato improbo ou ilegal, nem mesmo obteve qualquer proveito econômico em razão dos fatos alegados na exordial. Aduz que a inicial não aponta, de forma específica, a conduta improba perpetrada pela ré e que o Ministério Público não logrou demonstrar a existência de dolo e má-fé por parte da requerida. Sustenta que a prova produzida é frágil e que as atribuições do cargo que ocupava não lhe conferiam competência para verificar se os serviços discriminados nas notas fiscais foram de fato prestados, não cometendo nenhuma fraude. Aduz que os empenhos foram emitidos por determinação do Prefeito de forma correta e que não tinha acesso ao Setor de Tributação do Município, não sabendo sequer manusear o sistema. Refutou a alegação de que tinha conhecimento de que os valores supostamente desviados foram empregados no pagamento de gastos de campanha do requerido Roni. Informou ainda que não houve dano ao erário e nem enriquecimento sem causa, requerendo a improcedência da ação.

Robson e Sérgio também ofertaram contestação (fls. 1843/1868) e, em breve síntese, sustentaram que não se beneficiaram de qualquer forma em razão dos fatos alegados na inicial e que tão somente realizavam a liquidação dos empenhos, não sendo os responsáveis pela conferência da prestação dos serviços. Aduzem que não agiram com o intuito de lesar o erário ou de enriquecer injustamente e que sempre atuaram seguindo ordens superiores, de boa-fé. Aduzem que, em razão de suas funções, não possuíam condições de identificar a ocorrência de qualquer ilícito. Afirmam ainda que não agiram com dolo ou má-fé, não havendo provas de que praticaram qualquer irregularidade. Requereram a improcedência da ação.

O requerido Jean contestou a ação (fls. 1888/1914) aduzindo, de forma preliminar, a inépcia da petição inicial. No mérito aduziu, em suma, que não praticou quaisquer atos de improbidade administrativa, nem se beneficiou financeiramente de qualquer forma. Aduz que contribuiu de forma espontânea para o esclarecimento dos fatos e que não subscreveu as notas fiscais nem recebeu pagamentos indevidos. Alega que prestou os serviços contratados, não praticando qualquer ilegalidade. Impugnou a assinatura lançada no cheque em que consta como emitente. Requereu a improcedência da ação.

Roni compareceu aos autos, outorgando poderes para seu patrono receber citação (fls. 1995) e, como contestação, reiterou a defesa preliminar apresentada às fls. 1448/1478 (fls. 2002). Afirmou que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação vez que não concorreu, de qualquer forma, para a prática dos atos de improbidades administrativa indicados na exordial. Aduz que não autorizou quaisquer dos pagamentos indicados pelo "Parquet" e nem recebeu quaisquer valores. Aduz que não agiu de maneira culposa e que foi induzido a erro, não podendo ser responsabilizado pelos fatos narrados na inicial. Requereu a improcedência da ação.

O requerido Diego apresentou sua contestação quando da abertura do prazo para resposta preliminar (fls. 1620/1626) alegando, em resumo, que não há provas de que praticou qualquer ato de improbidade administrativa. Aduz que não agiu com dolo ou mesmo culpa, não podendo ser responsabilizado pelos danos indicados na exordial. Requereu a improcedência da ação.

A requerida Fercal não apresentou contestação (fls. 2006).

O Ministério Público apresentou réplica às fls. 2012/2017.

O feito foi saneado.

A instrução foi realizada com produção de prova oral

Encerrada a instrução, o Ministério Público e os requeridos Natascha e Roni apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Conforme escólio de José Afonso da Silva, a probidade administrativa consiste no dever de o "funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer. O desrespeito a esse dever é que caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada. A improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem" (Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª Ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2005, p. 669).

A improbidade administrativa pode ser definida como "a corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídica (Estado de Direito, Democrático e Republicano) revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos" (Pazzagli Filho, Marino; Elias Rosa, Márcio Fernando e Fazzio Júnior, Waldo. Improbidade Administrativa, Editora Atlas, 1996,

p. 35).

O caráter sancionador da Lei 8.429/92 é aplicável aos agentes públicos que, por ação ou omissão, violem os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e notadamente: (a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); (b) causem prejuízo ao erário público (art. 10); (c) atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), compreendida nesse tópico a lesão à moralidade administrativa.

Cumprе consignar que a responsabilização dos agentes públicos por atos de improbidade deve se basear em provas concretas quanto aos atos que lhe são imputados, face às graves consequências que afetam a vida do eventual infrator.

Conforme escólio de Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira, "os atos de improbidade, que acarretam enriquecimento ilícito, previstos no art. 9.º da Lei 8.429/1992, referem-se à obtenção de qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1.º da Lei de Improbidade Administrativa", sendo certo que "a premissa central para configuração do enriquecimento ilícito é o recebimento da vantagem patrimonial indevida, quando do exercício da função pública" (Manual de Improbidade Administrativa; 2ª Ed., São Paulo: MÉTODO, 2014).

Ademais, conforme leciona Maria Sylvia Zanella de Pietro, não é toda e qualquer irregularidade que caracteriza a improbidade administrativa, "a rigor, qualquer violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da moralidade, do interesse público, da eficiência, da motivação, da publicidade, da impessoalidade e de qualquer outro imposto à Administração Pública pode constituir ato de improbidade administrativa. No entanto, há de se perquirir a intenção do agente, para verificar se houve dolo ou culpa, pois, de outro modo, não ocorrerá o ilícito previsto na lei", sendo que "a aplicação da lei de improbidade exige bom-senso, pesquisa da intenção do agente, sob pena de sobrecarregar-se inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, que podem ser adequadamente resolvidos na própria esfera administrativa. A própria severidade das sanções previstas na Constituição está a demonstrar que o objetivo foi o de punir infrações que tenham um mínimo de gravidade, por apresentarem consequências danosas para o patrimônio público (em sentido amplo), ou propiciarem benefícios indevidos para o agente ou para terceiros. A aplicação das medidas previstas na lei exige observância do princípio da razoabilidade, sob o seu aspecto de proporcionalidade entre meios e fins" (Direito Administrativo, Ed. Atlas, 13ª Ed., 2001, p. 687/689).

Para o reconhecimento de ato de improbidade, exige-se a presença de dolo nos casos dos artigos 9º e 11 - que coíbem o enriquecimento ilícito e o atentado aos princípios administrativos, respectivamente - e ao menos de culpa nos termos do art. 10, que censura os atos de improbidade que causem efetivo dano ao erário.

Ainda assim, é assente o entendimento no sentido de que para a configuração do ato ímprobo inserto em qualquer dos incisos do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, faz-se necessária não somente esteja presente o elemento subjetivo, consubstanciado no dolo ou culpa, como também o elemento objetivo, consubstanciado na lesão ao erário.

Oportuna transcrição jurisprudencial:

"ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 8.429/1992. ART. 10. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE FATO TÍPICO. RECURSO IMPROVIDO. O STJ entende que, para a configuração dos atos de improbidade administrativa, previstos no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, exige-se a presença do efetivo dano ao erário (critério objetivo) e, ao menos, culpa (elemento subjetivo).

Não caracterizado o efetivo prejuízo ao erário, ausente o próprio fato típico. Recurso conhecido e improvido" (STJ; REsp 1233502 / MG; Relator(a): Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098); Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 14/08/2012; Data da Publicação/Fonte: DJe 23/08/2012).

No caso em apreço, a prática dos atos de improbidade administrativa restou devidamente comprovada.

Com efeito, a prova é contundente no sentido de que os requeridos concorreram para o desvio de valores referentes a serviços que não foram prestados ao ente público Municipal, causando prejuízo aos cofres públicos, ao arrepio dos princípios da moralidade e legalidade.

De acordo com as provas colacionadas aos autos, todo o estágio de execução das despesas indicadas na exordial (empenho, liquidação e pagamento) se deu de maneira fraudulenta, vez que não houve efetiva prestação de serviços ou mesmo procedimento licitatório (ou sua dispensa) que justificasse tais despesas.

É o que se infere do depoimento de Sebastião Barbosa, representante da empresa FERCAL, ao afirmar às fls. 91/93 que não emitiu as notas fiscais nº 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 (documentos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - fls. 104, 122, 131, 140, 148, 154, 169, 181, 188, 196, 204, 217, 230, 241).

Ademais, houve pagamentos indevidos sem sequer a existência de notas fiscais, conforme se infere dos documentos de fls. 249/255.

Como é cediço, o empenho é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento. No caso em testilha, as requeridas Gisele e Natascha, ao empenharem as despesas descritas na inicial (cf. documentos de fls. 105, 108/111, 123, 126/127, 132, 135/136, 141, 144/145, 149/150, 155, 156, 159, 170/171, 173/174, 182, 183, 185, 189, 190, 193, 197, 198, 200, 205, 206, 209, 218/219, 222, 226, 231/232, 235, 240, 242/243 e 246), reconhecendo a obrigação de pagamento, agiram de forma artilosa, vez que tais despesas jamais haviam sido contraídas pelo erário.

Por sua vez, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, envolvendo todos os atos de verificação e conferência, desde a entrega do material ou a prestação do serviço até o reconhecimento da despesa. E, in casu, as requeridas Gisele e Natascha agiram também de forma maliciosa vez que jamais poderiam reconhecer que o credor cumpriu todas as obrigações constantes do empenho (cf. documentos de fls. 106, 124, 133, 142, 150), na medida em que não houve efetiva prestação dos serviços.

Da mesma forma, os pagamentos realizados não se deram de forma escoreita. A entrega de numerário ao credor do Estado deve ocorrer sempre de forma registrada, diretamente ao credor, o que não ocorreu no caso em testilha em que os pagamentos, autorizados pelo requerido Roni, foram feitos mediante emissão de cheques de titularidade do Município pelos requeridos Sérgio e Robson (cf. documentos de fls. 137, 146, 152, 158, 175, 186, 192, 202, 208, 216, 221, 229, 234, 245 e 253) com posterior desconto por Janaína (cf. depoimento prestado às fls. 138 e cheque de fls. 137), Antônio (cf. cheque de fls. 146), Diego (cf. cheques de fls. 152, 216, 229), Jaqueline (cf. depoimento prestado às fls. 167/168 e cheque de fls. 158), Osvaldo Francisco (cf. cheque de fls. 175), pelo próprio Robson (cf. cheque de fls. 192), Lucas Ferreira (cf. depoimento de fls. 203 e cheque de fls. 202), Lenilson (cf. cheque de fls. 208 e depoimento de fls. 211), Paulo Henrique (cf. cheque de fls. 234 e depoimento de fls. 237), e Fabiana (cf. cheque de fls. 245 e depoimento de fls. 247/248). Ademais, os cheques de fls. 186, 221 e 253 constam o Município

como beneficiário de modo a dificultar o beneficiário da compensação.

Frise-se que os atos de empenho, liquidação e pagamento sequer seguiram uma ordem cronológica, houve falsificação de assinaturas do recebedor do empenho, conforme laudo de fls. 334/338, sendo certo ainda que parte das notas fiscais sequer ostenta o mesmo objeto da nota correlata de empenho, o que demonstra o nítido dolo dos requeridos.

A participação do requerido Jean na empreitada fraudulenta é evidente, vez que, se passando pelo responsável legal da empresa FERCAL, assinou o recebimento de valores constantes de notas de liquidação relativas a serviços que não foram prestados (cf. laudo de fls. 334/338), bem como recebeu e descontou os cheques emitidos para pagamento dos serviços inexistentes (cf. documento de fls. 112).

Cioso registrar, nesse aspecto, que, segundo dispõe o art. 3º da Lei nº 8.429/92, responde pelo ato de improbidade todo aquele que, mesmo não sendo agente público, concorre para a sua prática ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta, como ocorre na espécie.

Os vários atos praticados, bem como sua natureza e contexto, demonstram a voluntariedade e consciência da ação dos acionados, que, em conluio, emitiram notas fiscais referentes a serviços não prestados e deram início à execução das despesas até o efetivo desfalque do erário, restando caracterizado o dolo ensejador dos atos de improbidade imputados na exordial.

Como se vê, os acionados, em conluio, desviaram diversas quantias dos cofres municipais, circunstância que conduz à inevitável conclusão pela existência de improbidade administrativa, em razão da violação dos princípios da administração pública, na forma do artigo 11, da Lei 8.429/92, notadamente o da legalidade e moralidade, bem como em decorrência do prejuízo ao erário, nos termos do artigo 10, incisos I e IX, da Lei de Improbidade Administrativa, uma vez que restou devidamente demonstrado que o desfalque se deu sem qualquer razão de direito, na medida em que não houve prestação de serviços, sendo nulos de pleno direito os negócios jurídicos descritos na inicial.

Neste particular, reside o ato de improbidade praticado pelas partes, tanto pelos agentes públicos - que participaram de toda a cadeia de execução ilegal das despesas (empenho, liquidação e pagamento) - quanto pelo particular Jean, que se utilizou da pessoa jurídica de seu genitor para tentar camuflar os desvios anteriormente ocorridos.

Não se pode negar, portanto, o dolo, estando presente o elemento anímico necessário à configuração da improbidade. Tal dolo é demonstrado ainda pelas tratativas mantidas entre Gisele e Jean constante das transcrições de fls. 317/326, em que os interlocutores demonstram plena consciência das ilicitudes cometidas.

No caso dos autos, bem é de ver que a conduta dos agentes extrapolou a simples má-administração, invadindo a seara da improbidade.

No mais, é pouco crível que a tese de que houve simples equívoco de natureza contábil e administrativa. Com efeito, a cadeia de inconsistências no decorrer de todo o procedimento de liquidação e pagamento revela a ocorrência de fraude, conluio e posterior tentativa de dissimulação (cf. se infere dos documentos de fls. 359/378), não se tratando de simples erro ou falha na execução dos serviços.

Ainda assim, o simples atendimento de ordem hierárquica superior não possui o condão de afastar a responsabilidade dos requeridos.

Tanto Sérgio e Robson, responsáveis pela emissão dos cheques, quanto Diego,

responsável por alguns dos descontos das cártulas, agiram com plena consciência da ilicitude, vez que todos os pagamentos relativos a contratos da Administração devem ser objeto de redobrada cautela.

Uma singela verificação entre as datas das notas de empenho, das notas fiscais eletrônicas e dos cheques seria suficiente para que percebessem a irregularidade dos pagamentos, de modo que o mandamento hierárquico superior se demonstrava manifestamente ilegal e seu cumprimento deveria ter sido recusado.

O requerido Roni, ao cancelar tal procedimento, também agiu de forma ilícita e dolosa, desbordando da simples inaptidão administrativa, vez que anuiu a autorizou os pagamentos sem exigir a regularidade das transações.

Não é crível que numa cidade pequena, com cerca de 26 mil habitantes, o Prefeito Municipal não saiba que valores eram pagos sem que houvesse qualquer prestação de serviços. Ressalte-se que o requerido Roni, na qualidade de Chefe do Poder Executivo, é responsável pelos atos de seus prepostos, posto que estes agem através da outorga pessoal de poderes, presumindo-se, portanto, que suas ações sejam de ciência e da conivência do Prefeito Municipal.

Todavia, em que pese tenha sido comprovado, a não mais poder, o desvio de valores públicos pelos acionados, não se demonstrou que tais valores foram acrescidos ilicitamente ao patrimônio dos envolvidos, pelo que não se cogita da ocorrência de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9º, da 8.429/92.

Com efeito, embora incontroverso o desconto dos cheques emitidos pela Administração Municipal não restou comprovada durante a instrução processual que qualquer dos acionados se locupletou com tais vantagens.

Da mesma forma, não vislumbro como sancionar a pessoa jurídica Fercal na medida em que tal empresa não participou de forma efetiva do conluio fraudulento, tendo sido utilizada como mero instrumento para a consecução dos desvios por Jean, devendo somente este ser responsabilizado nesta seara.

Caracterizada a prática dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 10 e 11, da Lei 8.429/92, passa-se à dosimetria das penas.

Nesse diapasão, cumpre consignar que a Lei de Improbidade Administrativa abarca atos de diferentes graus de lesividade, razão pela qual o seu art. 12 traz um rol de sanções, que podem ser aplicadas cumulativamente ou não, concedendo ao magistrado a oportunidade de adequar, no caso concreto, a reprimenda cabível àquela determinada conduta comprovada.

Na aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92, o julgador deverá levar em conta a extensão do dano causado, bem como a gravidade da conduta do agente, devendo as penas aplicadas guardar correlação às condutas praticadas, para que se atinja a sua finalidade repressiva e preventiva no combate à improbidade administrativa.

Destarte, as penas devem guardar equilíbrio com a gravidade do ilícito, a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido, mensurando-se, ainda, a reprovabilidade da conduta, a posição hierárquica do agente, o objetivo público da exemplaridade da resposta judicial e natureza dos bens jurídicos lesados.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “as sanções do art. 12 da Lei 8.249/92 não são necessariamente cumulativas, cabendo ao Magistrado a sua dosimetria, como deixa entrever o parágrafo único do mesmo dispositivo” (REsp 713537/GO, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, Publicação: 22.11.2007).

No mesmo sentido:

"A aplicação das sanções da Lei n. 8.429/92 deve ocorrer à luz do princípio da proporcionalidade, de modo a evitar sanções desarrazoadas em relação ao ato ilícito praticado, sem, contudo, privilegiar a impunidade. Para decidir pela cominação isolada ou conjunta das penas previstas no artigo 12 e incisos, da Lei de Improbidade Administrativa, deve o Magistrado atentar para as circunstâncias peculiares do caso concreto, avaliando a gravidade da conduta, a medida da lesão ao erário, o histórico funcional do agente público etc." (STJ, Resp nº 300.184/SP, Rel. Ministro Franciulli Netto, DJ de 03.11.2003).

Em relação à demandada Gisele, considerando os parâmetros acima firmados e levando em conta sua participação preponderante nos fatos, deve esta ser sancionada da seguinte forma: a) ressarcimento integral do dano, solidariamente com os demais requeridos; b) perda da função pública; c) suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos; d) pagamento de multa civil equivalente a duas vezes o valor do dano; e e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Em relação ao acionado Roni, o escarmento deve ser fixado da seguinte forma: a) ressarcimento integral do dano, solidariamente com os demais requeridos; b) perda da função pública; c) suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos; e d) pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano.

Em relação aos acionados Natascha, Robson e Sérgio, o escarmento deve ser fixado da seguinte forma: a) ressarcimento integral do dano, solidariamente com os demais requeridos; b) perda da função pública; e c) pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano.

Em relação ao acionado Diego, a sanção deve ser fixada da seguinte forma: a) ressarcimento integral do dano, solidariamente com os demais requeridos; e b) pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano.

Em relação ao acionado Jean, a reprimenda deve ser fixada da seguinte forma: a) ressarcimento integral do dano, solidariamente com os demais requeridos; b) pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano; e c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Frise-se que o valor integral do dano, considerando a somatória dos desfalques efetuados contra os cofres públicos, importa em R\$102.109,60 (cento e dois mil, cento e nove reais e sessenta centavos), sendo certo que todos os requeridos, com exceção do Município e da empresa Fercal, deverão ressarcir, de forma solidária, o valor apurado.

Em relação ao pedido de obrigação de fazer deduzido pelo Município, a pretensão comporta acolhida vez que a vulnerabilidade no sistema de emissão de notas fiscais Municipais permitiu que os requeridos engendrassem toda e empreitada criminosa, de modo que tal falha deve ser devidamente corrigida a fim de evitar que as fraudes se perpetuem.

Por fim, não é o caso de condenação dos requeridos por danos morais coletivos.

Para a configuração de dano moral coletivo, fazia-se necessária a demonstração clara e inconteste de que as condutas ímprobas praticadas, afora terem vulnerado a moralidade da Administração Pública - circunstância ínsita à própria responsabilização civil por ato de improbidade administrativa -, provocaram

profunda comoção ou abalo social nos munícipes, de modo a justificar a compensação pecuniária, o que definitivamente não ficou delineado nos autos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e, em consequência:

a) condeno a requerida GISELE SALESSE, qualificada nos autos, pela prática do ato de improbidade administrativa previsto nos artigos 10, incisos I, e IX, e 11, ambos da Lei 8.429/92, aplicando-lhe, em consequência, as seguintes sanções: a) ressarcimento integral do dano, solidariamente com os demais requeridos; b) perda da função pública; c) suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos; d) pagamento de multa civil equivalente a duas vezes o valor do dano; e e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

b) condeno o requerido RONI CLÁUDIO BERNARDI FERRAREZE, qualificado nos autos, pela prática do ato de improbidade administrativa previsto nos artigos 10, incisos I, e IX, e 11, ambos da Lei 8.429/92, aplicando-lhe, em consequência, as seguintes sanções: a) ressarcimento integral do dano, solidariamente com os demais requeridos; b) perda da função pública; c) suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos; e d) pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano;

c) condeno os requeridos NATASCHA LEITE DE ALMEIDA, ROBSON DA SILVA COUTINHO e SERGIO FERREIRA DIAS, qualificados nos autos, pela prática do ato de improbidade administrativa previsto nos artigos 10, incisos I, e IX, e 11, ambos da Lei 8.429/92, aplicando-lhes, em consequência, as seguintes sanções: a) ressarcimento integral do dano, solidariamente com os demais requeridos; b) perda da função pública; e c) pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano;

d) condeno o requerido DIEGO NOVAIS SEVERIANO DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do ato de improbidade administrativa previsto nos artigos 10, incisos I, e IX, e 11, ambos da Lei 8.429/92, aplicando-lhe, em consequência, as seguintes sanções: a) ressarcimento integral do dano, solidariamente com os demais requeridos; e b) pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano;

e) condeno o requerido JEAN PIERRE PEDROSO BARBOSA, qualificado nos autos, pela prática do ato de improbidade administrativa previsto nos artigos 10, incisos I, e IX, e 11, ambos da Lei 8.429/92, aplicando-lhe, em consequência, as seguintes sanções: a) ressarcimento integral do dano, solidariamente com os demais requeridos; b) pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano; e c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

f) declaro a nulidade dos negócios jurídicos firmados entre o Município e a empresa Fercal Comércio de Ferros e Calhas Ltda. - ME descritos na inicial; e

g) condeno o Município de Valparaíso ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em corrigir as vulnerabilidades de seu sistema de emissão de notas fiscais, promovendo o chamamento de todos os usuários para fins de troca de senha de acesso, bem como para que providencie o cancelamento dos encargos fiscais gerados indevidamente à empresa FERCAL.

Torno definitiva a ordem de indisponibilidade.

Sucumbentes em maior parte, arcarão os requeridos com as despesas processuais, observada eventual gratuidade processual.

Sem condenação em honorários advocatícios por falta de amparo legal.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Superior Instância, para apreciação de recurso de apelação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Valparaíso, 04 de abril de 2022.

FERNANDO BALDI MARCHETTI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA